

的到期债权予以否认的不予支持,但第三人如果没有否认生效法律文书确定的债权,而是提出异议称该债权已经清偿等,则构成异议,法院不能对第三人强制执行。如:

例:甲小额贷款公司起诉乙公司要求归还借款本金和利息共计80万元,获得胜诉判决后甲公司申请强制执行,乙公司没有可供执行的财产。在乙公司诉丙公司买卖合同纠纷一案中,某区法院已经作出生效判决,判令丙公司向乙公司支付货款80万元,该判决确定的履行期限已经届满。根据甲公司的申请,法院向丙公司发出履行到期债务的通知。丙公司在收到通知后15日内提出下列异议,法院分别应当如何处理?

(1) 丙公司称其与乙公司买卖合同纠纷的判决中认定事实错误,丙公司并不欠乙公司货款。

(2) 丙公司称其已经在收到法院通知之前向乙公司支付了该笔货款。

分析:(1) 丙公司提出异议否认生效判决所确定的到期债权,法院不予支持,该异议不影响履行通知的效力。

(2) 丙公司没有否认生效判决确定的到期债权,但提出该到期债权已经清偿,构成异议,法院不能对丙公司强制执行,对丙公司的异议不审查。

298. 陈某起诉顾某离婚,法院判决解除婚姻关系,同时判决婚生子陈小某由陈某抚养,顾某每月可探望两次。顾某多次要求探望,陈某均不予配合,顾某向法院申请强制执行。关于本案,法院可以采取下列哪些措施? (2021 金题-2-4-41, 多)

A. 法院可以将陈小某带至指定场所,由顾某行使探望权

B. 法院可以将顾某带至陈某住处行使探望权

C. 可以对陈某处以罚款

D. 可以对陈某处以拘留

【分析与思路】 本题考查《民法典婚姻家庭编解释(一)》关于对探望权实施强制措施的措施。根据该司法解释第68条的规定,对于拒不协助另一方行使探望权的有关个人或者组织,可以由人民法院依法采取拘留、罚款等强制措施,但是不能对子女的人身、探望行为进行强制执行。首先,民事执行的标的只能是财物的给付和行为

的履行,不能对人身强制执行,可以从两个角度理解,角度一,基于一个法律的基本原则,人是主体,绝对不能将人物化为客体或者对象;角度二,探望权本身是为了有利于子女的身心健康,如果对子女的人身、探望行为进行强制执行不仅对子女身心健康不利,反而可能带来不利影响。其次,陈某拒不配合顾某行使生效法律文书所确定的权利,构成妨碍执行,可以对其处以罚款、拘留。综上所述,对于探望权的强制执行,不能对被探望人的人身、探望行为强制执行,但可以追究拒不协助另一方行使探望权的有关个人或者组织的法律责任,迫使其积极履行协助义务。结合本案,A选项是对子女的人身进行强制执行,表述错误;B选项是对探望行为进行强制执行,表述错误;C、D选项表述正确。

综上所述,本题答案为CD。

299. 田某拒不履行法院令其迁出钟某房屋的判决,因钟某已与他人签订租房合同,房屋无法交给承租人,使钟某遭受损失,钟某无奈之下向法院申请强制执行。法院受理后,责令田某15日内迁出房屋,但田某仍拒不履行。关于法院对田某可以采取的强制执行措施,下列哪些选项是正确的? (2016-3-84, 多)

A. 罚款

B. 责令田某向钟某赔礼道歉

C. 责令田某双倍补偿钟某所受到的损失

D. 责令田某加倍支付以钟某所受损失为基数的同期银行利息

【分析与思路】 本案考查逾期履行生效法律文书确定义务的责任以及妨碍执行的法律责任。首先,田某不在生效法律文书确定的履行期限内履行生效法律文书确定的义务,构成迟延履行。对于迟延履行的,应当区分情形处理:如果是逾期履行金钱给付义务的,加倍计算迟延履行期间债务利息;如果是逾期履行非金钱给付义务的,则应当计算迟延履行金。本案中生效判决书确定的内容为责令田某迁出房屋,并非金钱给付义务,不能加倍计算利息,应当计算迟延履行金。关于迟延履行金的计算,根据《民事诉讼法解释》规定,如果造成权利人损失的,双倍补偿权利人损失,如未造成损失,由法院根据具体案件情况确定。本题题目明确已经给权利人钟某造成损失,

故应当双倍补偿其损失作为迟延履行金。故 C 选项责令田某双倍补偿钟某的损失作为迟延履行金为正确表述,而 D 选项加倍计算利息的表述为错误。同时,法院采取强制执行措施,责令田某迁出房屋,田某仍拒绝履行的行为构成妨碍执行,法院可以对其采取拘留、罚款措施, A 选项正确。而本案跟赔礼道歉无关, B 选项错误。

综上所述,本题答案为 AC。

【命题思路与常见错误分析】 首先本题 A 选项考查妨碍执行的法律责任,当法院采取强制执行措施,责令田某 15 日内迁出房屋,田某拒不履行,构成妨碍执行,可以对其采取拘留、罚款措施。其次,田某未在生效判决确定的期限内履行义务,构成迟延履行,涉及迟延履行的法律责任,需要区分迟延履行金钱债务和迟延履行非金钱债务。本题生效法律文书确定的义务为“迁出房屋”,为非金钱债务,应当是计算迟延履行金,而不涉及加倍支付利息问题。有同学误选 D 选项,则是因为不能明确区分迟延履行金和加倍支付利息的适用情形所致。

300. 甲公司诉乙公司合同纠纷一案,诉讼中, A 区法院根据甲公司的申请,冻结乙公司 100 万元银行存款。该案经法院终审判决甲公司胜诉,甲公司向 A 区法院申请执行。此时, B 区法院受理乙公司的破产申请。A 区法院应当如何处理?
(2024 金题-2-4-37, 单)

- A. 中止执行,待 B 区法院宣告破产后终结执行,将冻结的存款交管理人
- B. 中止执行,将冻结的存款移交管理人
- C. 继续执行,将冻结的存款划扣给甲公司
- D. 终结执行,将冻结的存款移交管理人

【分析与思路】 本题考查法院受理破产申请对执行程序的影响。根据《破产法》第 19 条规定,法院受理破产申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。故本案中 B 区法院已经受理了乙公司的破产申请,甲公司申请 A 区法院对乙公司的执行程序应当中止, A 区法院应当解除对乙公司 100 万元存款的冻结,故 C、D 选项错误, A、B 选项中关于中止执行的表述正确。

A 区法院裁定中止执行,解除冻结后对已经冻结的财产应当如何处理? B 区法院受理乙公司破产申请时应当为乙公司指定管理人,同时乙公司的财产属于债务人财产,应当由管理人进行管理和处分,故 A 区法院在中止执行,解除冻结后即应当将已经冻结的存款交由管理人进行管理和处分,而不是在 B 区法院宣告乙公司破产后再将冻结的存款交管理人,故 B 选项正确, A 选项错误。当然,此时甲公司作为债权人可以根据生效判决书向管理人申报债权。

综上所述,本题答案为 B。

PROJECT 26

专题二十六 涉外民事诉讼程序

考 点 必 背

一、两个重点原则

1. 委托中国律师代理诉讼：外国当事人在我国参加诉讼，需要委托律师代理诉讼的，只能委托中国律师代理诉讼，即外国律师不能以律师身份参加诉讼，但是并不妨碍外国人以非律师身份担任委托代理人。

2. 使用中国语言、文字进行诉讼：人民法院审理涉外民事案件，应当使用中国通用的语言、文字。当事人要求提供翻译的，可以提供，费用由当事人承担。

二、管辖

1. 专属管辖。下列案件，由人民法院专属管辖，外国法院不准管：（1）因在中国领域内设立的法人或者其他组织的设立、解散、清算，以及该法人或者其他组织作出的决议的效力等纠纷提起的诉讼；（2）因与在中国领域内审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷提起的诉讼；（3）因在中国领域内履行中外合资经营企业合作合同、中外合作经营企业合作合同、中外合作勘探开发自然资源合同发生纠纷提起的诉讼。

2. 协议管辖。（1）涉外民事纠纷的当事人书面协议选择人民法院管辖的，可以由人民法院管辖。（2）涉外民事纠纷当事人订立排他性管辖协议选择外国法院管辖且不违反《民事诉讼法》对专属管辖的规定，不涉及中华人民共和国主权、安全或者社会公共利益的，人民法院可以裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。

注意：涉外民事纠纷中，当事人只要通过书面协议选择人民法院管辖的，人民法院就有管辖权，不要求争议与中国有实际联系。

3. 牵连管辖。因涉外民事纠纷，对在中国领域内没有住所的被告提起除身份关系以外的诉讼，纠纷与中国存在适当联系的，可以由人民法院管辖。

4. 应诉管辖。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩或者提出反诉的，视为人民法院有管辖权。

三、平行诉讼

1. 专属管辖、协议管辖以及案件涉及中国主权、安全和社会公共利益的，不存在平行诉讼的问题。

（1）专属于人民法院管辖的案件，按照专属管辖确定由人民法院管辖。

（2）当事人存在管辖协议的案件，按照当事人的管辖协议确定管辖法院。

（3）案件涉及中国主权、安全或者社会公共利益的一定由中国法院管辖。

2. 牵连管辖的情形下，案件有可能外国法院和中国法院都有管辖权，称之为平行诉讼。既然人民法院有管辖权，故不论外国法院是否受理案件，当事人向人民法院起诉的，人民法院都可以受理。受理之后怎么办？

（1）不方便法院原则：人民法院审理更方便的由人民法院管辖；如果案件基本事实没有发生在中国，在中国进行诉讼不方便，在外国法院进行诉讼更方便的，被告提出管辖权异议，人民法院裁定驳回起诉，告知当事人向外国法院起诉（方便当事人向更方便的外国法院起诉）。

(2) 先受理法院规则：人民法院受理案件后，当事人以外国法院已经先于人民法院受理为由，书面申请人民法院中止诉讼的，人民法院可以裁定中止诉讼（方便当事人到先受理案件的外国法院应诉）。

注意，法院以不方便法院原则为由裁定驳回起诉是为了方便当事人去更方便的外国法院起诉，以先受理法院规则为由裁定诉讼中止是为了方便当事人到先受理案件的外国法院应诉，所以：

①方不方便应当由当事人自己判断，故必须要求当事人提出管辖权异议或者诉讼中止的书面申请；

②如果外国法院拒绝行使管辖权，未采取必要措施审理案件，或者未在合理期限内审结的，当事人向人民法院起诉，或者申请人民法院恢复审理的，中国法院应当依法受理，或者恢复审理。

四、期间与送达

1. 4个特殊规定只看住所不看国籍：特殊的送达方式，特殊的上诉期、答辩期、对上诉状的答辩期（30天）；

2. 所有的涉外民事案件都不受一审、二审审限限制。

五、司法协助

1. 代为调查取证、送达文书

根据国际条约，或者按照互惠原则，人民法院和外国法院可以相互请求，代为送达文书、调查取证以及进行其他诉讼行为。外国驻中国使领馆可以向该国公民送达文书和调查取证，但不得违反中国法律，不得采取强制措施。人民法院提供司法协助，依照中国法律规定的程序进行。外国法院请求采用特殊方式的，也可以按照其请求的特殊方式进行，但不得违反中国法律。

2. 对外国法院裁判、仲裁裁决书的承认与执行

(1) 外国法院的判决、裁定在中国的承认和执行有两条路：①当事人直接向有管辖权的中院申请承认和执行；②外国法院依照国际条约的规定，或者按照互惠原则，请求人民法院承认和执行。

外国仲裁机构的仲裁裁决在中国的承认和执行只有一条路：当事人可以直接向被执行人住所地或其财产所在地的中院申请。

(2) 当事人申请承认和执行的外国判决、裁定所涉及的纠纷与人民法院正在审理的纠纷属于同一纠纷的，人民法院可以裁定中止诉讼：①人民法院裁定不予承认和执行外国法院判决、裁定的，恢复已经中止的诉讼；②人民法院裁定承认和执行外国法院判决、裁定的，对已经中止的诉讼，裁定驳回起诉。

(3) 当事人对承认和执行或者不予承认和执行的裁定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。

301. 2012年1月，中国甲市公民李虹（女）与美国留学生琼斯（男）在中国甲市登记结婚，婚后两人一直居住在甲市B区。2014年2月，李虹提起离婚诉讼，甲市B区法院受理了该案件，适用普通程序审理。关于本案，下列哪些表述是正确的？（2014-3-84，多）

A. 本案的一审审理期限为6个月

B. 法院送达诉讼文书时，对李虹与琼斯可采

取同样的方式

C. 不服一审判决，李虹的上诉期为15天，琼斯的上诉期为30天

D. 美国驻华使馆法律参赞可以个人名义作为琼斯的诉讼代理人参加诉讼

【分析与思路】 本题考查涉外民事诉讼程序。

首先，本案的一方当事人是美国人，为涉外民事诉讼程序，涉外民事诉讼程序不受一审、二审审

限的限制,所以A选项表述错误。其次,关于送达,值得注意的是适用涉外送达规定的前提是受送达人在中国境内没有住所,所以本案中琼斯在中国境内有住所,不适用涉外送达的特殊规定,只能适用国内送达的规定,与对李虹的送达方式相同,B选项表述正确。再次,C选项中关于上诉期的问题,答辩期、上诉期、被上诉人的答辩期为30天并可以延长的特殊规定仅适用于在中国境内没有住所的当事人,而本案琼斯虽然是外国人,但在中国境内有住所,所以上诉期依然适用国内民事诉讼的规定,为15天而不是30天,C选项表述错误。最后,外国驻华使、领馆官员,受本国公民的委托,可以以个人名义担任诉讼代理人,但在诉讼中不享有外交特权和豁免权,所以D选项正确。

综上所述,本题答案为BD。

总结与归纳:

涉外民事诉讼中的有些特殊规定适用于所有涉外民事案件,而有些特殊规定仅仅适用于在中国没有住所的当事人,这是考试考查的重点。

1. 关于审限问题,所有涉外民事诉讼,均不受一审、二审审限的限制。
2. 关于(1)送达方式、(2)上诉期、(3)答辩期、(4)被上诉人的答辩期的特殊规定,仅仅适用于在中国境内没有住所的当事人,即只看住所不看国籍。

302. 金某和全某是外国人,二人结婚后长期在中国居住,且通晓中文。全某与曹某发生争执,曹某将全某打伤,全某向法院起诉曹某要求赔偿医疗费等各项损失,关于本案,下列表述正确的是?(2025金题-2-4-30,多)

- A. 全某可委托金某担任诉讼代理人
- B. 法院可发送中文和外文判决书,并加盖法院印章
- C. 法院可不提供中文翻译
- D. 本案由中院审理

【分析与思路】 本题考查涉外民事诉讼程序的一些简单考点。首先,委托中国律师代理诉讼原则仅仅禁止外国律师以律师身份担任代理人,并不禁止外国人担任代理人,故金某虽然是外国人,但仍然可以担任全某的诉讼代理人,A选项正确。其次,根据《民事诉讼法》第273条规定,“人民

法院审理涉外民事案件,应当使用中华人民共和国通用的语言、文字。当事人要求提供翻译的,可以提供,费用由当事人承担。”一方面,基于维护国家主权和司法尊严,人民法院审理涉外民事案件必须使用中国语言、文字,即法官说中文,用中文发送诉讼文书;另一方面,为了便于外国当事人进行诉讼,可以根据当事人的要求提供翻译,但当事人自行承担费用。故法院应当用中国文字发送判决书,不能发送外文判决书。当然,可以根据当事人的要求提供翻译,值得注意的是,外文翻译的判决书不得加盖人民法院印章。(试想,一份全是外文的判决书最后加盖了人民法院印章,不合适吧!)故B选项错误。再次,“当事人要求提供翻译的,可以提供”,即就算当事人要求提供翻译的,人民法院也是“可以”提供,何况本案中当事人并没有要求提供翻译,故法院可以不提供翻译,C选项正确。最后,只有重大涉外案件由中院管辖,本案只是普通涉外民事案件,不满足“重大”的要求,应当由基层法院管辖,D选项错误。

综上所述,本题答案为AC。

背下来:

人民法院审理涉外民事案件,应当适用中国通用语言、文字,当事人要求提供翻译的,可以提供,费用由当事人自行承担。

只有重大涉外案件才由中院管辖,一般的涉外案件由基层法院管辖。

303. 居住在广州市白云区的张某跟瑞典某公司在广州市海珠区签订了设备买卖合同,后来因为该合同的履行发生纠纷,该公司根据瑞典法律规定向瑞典的法院提起诉讼,瑞典法院受理了案件;张某认为本案由中国法院管辖更方便,遂向广州市海珠区人民法院起诉。海珠区法院受理了本案,并作出了判决。关于本案,表述正确的是?(2019金题-2-4-29,多)

- A. 海珠区法院受理本案并作出判决的做法是正确的
- B. 本案属于重复起诉,海珠区法院不应当受理
- C. 该公司申请我国法院承认并执行瑞典法院的判决,人民法院不予准许
- D. 该公司和张某对海珠区法院的一审判决不服,上诉期为30天

[分析与思路] 本题综合考查涉外民事诉讼程序。

首先, 张某向海珠区法院起诉, 海珠区法院应否受理? 第一, 海珠区法院是否有管辖权? 本案是涉外民事纠纷, 海珠区作为合同签订地, 与案件存在适当联系, 故海珠区法院有管辖权。第二, 瑞典法院已经受理本案, 张某向海珠区法院起诉, 海珠区法院应否受理? 本案瑞典法院和中国法院都有管辖权, 属于平行诉讼, 只要人民法院有管辖权, 不论外国法院是否受理案件, 当事人向人民法院起诉的, 人民法院都可以受理。故海珠区法院受理本案并作出判决的做法正确, A 选项正确, B 选项错误。

其次, 既然海珠区人民法院受理了本案并已经作出判决, 故当事人申请法院承认并执行瑞典法院的判决, 我国法院不予支持——因为一旦我们裁定承认瑞典法院的判决, 该裁定就会和海珠区法院对本案作出的判决冲突, C 选项正确。当然, 我们补充一个问题, 该公司申请我国法院承认并执行瑞典法院的判决, 人民法院裁定不予承认、执行, 该公司对该裁定不服, 应当如何救济呢? 根据《民事诉讼法》第 303 条规定, 当事人对承认和执行或者不予承认和执行的裁定不服的, 可以自裁定送达之日起 10 日内向上一级人民法院申请复议。

最后, 本题 D 选项考查涉外民事诉讼中上诉期的特殊规定, 我们一再强调, 30 天特殊上诉期的规定仅仅适用于在中国没有住所的当事人, 故本案中, 某公司在中国没有住所, 上诉期为 30 天, 而张某在中国有住所, 其上诉期为 15 天, D 选项表述错误。

综上所述, 本题答案为 AC。

背下来:

1. 中国法院有管辖权的案件, 当事人向中国法院起诉, 中国法院都可以受理, 不论外国法院是否受理案件。
2. 人民法院已对同一纠纷作出判决、裁定, 当事人申请承认、执行外国法院对本案的判决、裁定的, 不予支持。

304. J 国公民杰森和中国公民吴某在中国签订《买卖合同》, 在合同履行过程中, 杰森向 J 国法院请求解除合同, J 国已经受理本案 (A 诉讼); 吴某亦向合同签订地的中国法院起诉杰森请求支

付合同货款 (B 诉讼)。关于本案, 中国法院应当如何处理? (2024 金题-2-4-38, 单)

- A. 中国法院应当受理本案后, 裁定诉讼中止
- B. 因 A 诉讼和 B 诉讼是对抗关系, 故中国法院应当对吴某的起诉不予受理
- C. 因 A 诉讼和 B 诉讼是对抗关系, 故中国法院应当裁定驳回吴某起诉
- D. 中国法院应当受理吴某的起诉, 继续审理

[分析与思路] 本题考查平行诉讼 (对抗诉讼) 的问题。本案 J 国法院和中国法院都有管辖权, 故称之为平行诉讼 (对抗诉讼)。关于平行诉讼问题, 我们讲三步走: 第一步, 本案没有专属管辖, 没有协议管辖, 不涉及中国主权、安全、公共利益, 故本案可以讨论平行诉讼问题; 第二步, 平行诉讼, 不论外国法院是否受理, 当事人向中国法院起诉的, 中国法院都可以受理, 故本案吴某向中国法院起诉, 中国法院应当依法受理, B、C 选项错误。第三步, 受理之后怎么办? 存在两个问题, 一是不方便法院原则, 二是先受理法院规则。

关于不方便法院原则, 如果案件基本事实没有发生在中国, 在中国进行诉讼不方便, 在外国法院进行诉讼更方便的, 被告提出管辖权异议, 人民法院裁定驳回起诉, 告知当事人向更方便的外国法院起诉。

关于先受理法院规则, 人民法院受理案件后, 当事人以外国法院已经先于人民法院受理为由, 书面申请人民法院中止诉讼的, 人民法院可以裁定中止诉讼。

值得注意的是, 以不方便法院原则为由裁定驳回起诉是为了方便当事人去更方便的外国法院起诉, 以先受理法院规则为由裁定诉讼中止是为了方便当事人到先受理案件的法院应诉, 都是为了方便当事人, 故应当以当事人提出管辖权异议或者诉讼中止的书面申请为前提。本案中虽然 J 国法院已经先于人民法院受理案件, 但当事人并没有提出诉讼中止的书面申请, 故人民法院不能依职权裁定诉讼中止, 而应当继续审理, 故本题 A 选项错误, D 选项正确。

综上所述, 本题答案为 D。

[命题思路与常见错误分析] 本题考查平行诉讼 (中国法院和外国法院都有管辖权的案件) 制度。考点有二: 首先, 当事人向中国法院起诉, 只要中国法院依法有管辖权的, 都可以受理, 不

论外国法院是否已经受理案件。其次，法院受理案件后，可以以外国法院先受理案件为由裁定诉讼中止，但以当事人提出书面申请为前提。

背下来：人民法院以不方便法院原则为由裁定驳回起诉或者以先受理法院规则为由裁定诉讼中止都是为了方便当事人，故必须以当事人提出管辖权异议或者书面申请为前提。

305. H国星辉公司与中国A市的益华公司订立买卖合同，合同中约定因为履行本合同发生纠纷应当在H国S市法院适用《中华人民共和国民事诉讼法》解决。后双方达成补充协议，约定发生纠纷既可以向H国S市法院起诉，也可以由中国A市仲裁委适用《H国国际仲裁中心仲裁规则》仲裁。现在双方因为履行合同发生纠纷，关于纠纷的解决方式，下列表述正确的是？（2021 金题-2-4-35，单）

- A. 可以由H国S市法院适用《中华人民共和国民事诉讼法》解决纠纷
- B. 可以由中国A市仲裁委适用《H国国际仲裁中心仲裁规则》进行仲裁
- C. 可以由中国A市仲裁委适用A市仲裁委仲裁规则进行仲裁
- D. 可以由H国S市法院适用H国民事诉讼法解决

【分析与思路】 本题考查仲裁协议的效力以及民事诉讼法的效力问题。

首先判断主管问题，当事人对纠纷解决方式的约定为：发生纠纷既可以向H国S市法院起诉，也可以由中国A市仲裁委仲裁。该仲裁协议约定了或裁或审，仲裁协议无效，故当事人不能向中国A市仲裁委申请仲裁，B、C选项错误。当然，本案是涉外民事纠纷，当事人可以协议选择与争议有实际联系的外国法院管辖，本案当事人约定

由H国S市法院管辖，该管辖协议有效，当事人可以依据该管辖协议向H国S市法院起诉。

其次判断法律适用问题，既然当事人应当根据管辖协议向H国S市法院起诉，关于H国S市法院应当适用中国民法还是H国民法审理的问题，我们在讲中国民事诉讼法的效力问题强调过，因为民事诉讼法是公法，涉及国家审判权问题，故只要在中国进行民事诉讼，必须适用中国民事诉讼法，不存在由中国法院适用外国民事诉讼法的问题；同样的道理，H国法院审理民事案件也必须适用H国民事诉讼法，不存在适用中国民事诉讼法的问题。故A选项错误，D选项正确。

综上所述，本题答案为D。

【命题思路与常见错误分析】 本题设置了一个涉外民事纠纷，涉及仲裁、法院管辖以及民事诉讼法的适用问题，看似国际私法问题，但同学们只要逐一剥离出题目中的考点，即可用民事诉讼法中的简单制度以及原理予以分析。首先应当看到的是关于纠纷的解决，题目中给出一个或裁或审的仲裁协议，涉及仲裁协议效力这一考点。其次同学们只需要通过民事诉讼法属于公法，在任何国家进行民事诉讼都只能适用该国民事诉讼法，不存在适用别国民事诉讼法的问题这一简单原理即可选出正确答案。

当然，本题补充一个问题，如果去掉仲裁协议无效这一考点，当事人直接约定“发生纠纷由A市仲裁委适用《H国国际仲裁中心仲裁规则》进行仲裁”，那当事人当然应当向A市仲裁委申请仲裁，问题是A市仲裁委能否根据当事人的约定适用《H国国际仲裁中心仲裁规则》进行仲裁呢？答案是肯定的。因为仲裁委是一种社会组织，是根据当事人的意愿解决纠纷，不涉及国家审判权的行使，亦不涉及国家司法主权问题，故可以由当事人对适用的仲裁规则进行约定。

PROJECT 27

专题二十七 仲裁概述

考点必背

1. 仲裁仅限于平等主体之间的财产纠纷，婚姻、收养、监护、扶养、继承等涉及身份关系的纠纷不能仲裁；劳动争议适用劳动仲裁，与民商事仲裁无关。
2. 仲裁应当遵循诚信原则。仲裁庭发现当事人单方捏造基本事实申请仲裁或者当事人之间恶意串通，企图通过仲裁方式侵害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，应当驳回其仲裁请求。
3. 仲裁活动可以通过信息网络在线进行，但当事人明确表示不同意的除外。仲裁活动通过信息网络在线进行的，与线下仲裁活动具有同等法律效力。

306. 黄蜂公司和白云公司因为合同纠纷向 A 仲裁委申请仲裁，仲裁庭在审理本案中发现黄蜂公司和白云公司恶意串通，通过仲裁方式转移财产以逃避债务，仲裁庭可以如何处理？（2024 金题-2-4-41，单）

- A. 报仲裁委所在地中院，中院对其罚款
- B. 在裁决书里对虚假仲裁行为予以谴责
- C. 裁决驳回仲裁申请
- D. 移送公安机关以虚假诉讼罪追究刑事责任

【分析与思路】仲裁应当遵循诚信原则，仲裁庭发现当事人单方捏造基本事实申请仲裁或者当事人之间恶意串通，企图通过仲裁方式侵害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，应当驳回其仲裁请求。在本案中，黄蜂公司和白云公司恶意串通，通过仲裁方式逃避债务，侵害债权人合法权益，仲裁庭应当裁决驳回其仲裁请求，C 选项正确。仲裁裁决书是只对当事人的仲裁申请作出支持与否的裁决，在裁决中把当事人骂一顿没有意义，B 选项错误。在民事诉讼中进行虚假

诉讼，妨碍人民法院审理案件的，法院可以对当事人予以罚款、拘留，故罚款、拘留作为对妨碍诉讼的一种强制措施，应当由法院决定，且适用于妨碍人民法院进行诉讼、执行的情形，虚假仲裁没有妨碍法院的诉讼秩序、执行秩序，不能适用民事诉讼法中的强制措施，A 选项错误。D 选项其实是一个刑法问题，根据《刑法》第 307 条之一规定“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的”构成虚假诉讼罪，该罪名是《刑法》分则第六章“妨害社会管理秩序罪”中的第二节“妨害司法罪”，其犯罪客体是司法秩序以及他人合法权益，而虚假仲裁的行为并未进入司法程序，没有妨害司法秩序，不构成虚假诉讼罪。但值得注意的是，如果当事人通过虚假仲裁的方式获得了仲裁裁决后向法院申请执行仲裁裁决，则妨害司法秩序，构成本罪。

综上所述，本题答案为 C。

PROJECT 28

专题二十八 仲裁协议

考点必背

1. 仲裁协议是仲裁的基础。仲裁协议形式上必须是书面，内容上要包括：(1) 请求仲裁的意思表示；(2) 可仲裁的仲裁事项；(3) 明确选定的仲裁机构。

关于仲裁协议，需要注意以下规则：

(1) 仲裁协议中约定的仲裁机构不存在的，仲裁协议无效（仲裁机构最低设置在设区的市，区、县没有仲裁机构）。

(2) 当事人约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体仲裁机构的，仲裁协议有效。

(3) 仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。

(4) 仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。

(5) 当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向法院起诉的，仲裁协议无效；但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁庭首次开庭前提出异议的除外。

2. 当事人达成仲裁协议，一方向法院起诉未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，法院应当继续审理。仲裁协议效力独立存在，合同是否成立及其变更、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力。

3. 仲裁协议的效力具有相对性，仅仅对仲裁协议的当事人有约束力，但仲裁协议效力存在如下三种扩张的情形：

(1) 当事人订立仲裁协议后合并、分立的，仲裁协议对其权利义务的继受人有效，当事人另有约定的除外。

(2) 当事人订立仲裁协议后死亡的，仲裁协议对承继其仲裁事项中的权利义务的继承人有效，当事人另有约定的除外。

(3) 债权债务全部或者部分转让的，仲裁协议对受让人有效，但当事人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外。

4. 当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定，也可以请求申请人住所地、被申请人住所地、仲裁协议签订地或者仲裁机构所在地中级人民法院作出裁定。一方向法院申请确认、一方向仲裁机构或仲裁庭申请确认，法院的确认权优先，但仲裁机构或仲裁庭先于法院接受申请，并已经作出决定的，法院不予受理。

5. 当事人对仲裁协议效力有异议应当在仲裁庭首次开庭前提出：

(1) 一方申请仲裁，另一方在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议效力提出异议，而后向法院申请确认仲裁协议效力的，法院不予受理；仲裁庭作出裁决后，当事人以仲裁协议无效为由向法院提出撤销、不予执行仲裁裁决的，不予支持。

(2) 一方当事人在申请仲裁时主张有仲裁协议，另一方当事人在首次开庭前不予否认的，经仲裁庭提示并记录，视为当事人之间存在仲裁协议。

307. A市B区蓝月公司与C市D县新辉公司在D县签署仓储合同,合同约定双方因为履行该合同发生纠纷,应当向E县仲裁委申请仲裁。合同履行过程中,新辉公司与F市G区顶力公司合并成立了新立公司(F市G区),后来蓝月公司拖欠仓储费用,新立公司欲追究其违约责任,下列纠纷解决途径表述正确的是?(2018金题-2-4-9,单)

- A. 本案新立公司不能向仲裁委申请仲裁,因为仲裁协议对合并后的新立公司不产生约束力
- B. 本案新立公司可以向D县人民法院提起诉讼
- C. 本案新立公司可以向B区法院提起诉讼
- D. 本案新立公司可以向E县仲裁委申请仲裁

【分析与思路】蓝月公司与新辉公司签订仓储合同,合同中约定发生纠纷由E县仲裁委仲裁,显然,仲裁机构最低设在设区的市一级,区、县没有仲裁机构,故该仲裁协议约定的仲裁机构不存在,仲裁协议无效。同时在合同履行中新辉公司与顶力公司合并成立了新立公司,此时涉及仲裁协议效力的扩张这一考点。据此分析选项,首先仲裁协议约定的E县仲裁委不存在,仲裁协议无效,新立公司不能向E县仲裁委申请仲裁,当然,也没有所谓的E县仲裁委,D选项错误。其次A选项中新立公司不能向仲裁委申请仲裁这一结论是正确的,究其原因仲裁协议约定的仲裁机构不存在,仲裁协议无效,而表述中给出的理由是仲裁协议对合并后的新立公司不产生约束力错误,因为仲裁协议签订后,当事人合并、分立的,仲裁协议对其权利义务的继受人有约束力,故A选项表述错误。本案仲裁协议无效,发生纠纷后当事人应当通过诉讼方式解决纠纷,本案是合同纠纷,且不存在专属管辖,没有管辖协议,故应当由被告住所地或者合同履行地法院管辖,首先被告蓝月公司住所地为B区,同时本案合同纠纷没有约定履行地,新立公司起诉蓝月公司要求支付费用,属于要求给付货币,应当由接收货币方即新立公司住所地(F市G区)为合同履行地,故本案新立公司可以向B区或者G区法院起诉,故本题C选项表述正确,而B选项中表述的D县法院是合同签订地法院,没有管辖权,故B选项表述错误。

综上所述,本题答案为C。

【命题思路与常见错误分析】本题考查仲裁协议的效力以及合同纠纷的管辖。涉及三个考点,一是仲裁机构最低设立在设区的市、区、县没有仲裁机构,仲裁协议无效;二是仲裁协议效力的扩张,当事人订立仲裁协议后合并、分立的,仲裁协议对合并、分立后的当事人有约束力;三是既然仲裁协议无效,本案属于法院主管,合同纠纷由被告住所地或者合同履行地法院管辖,同时合同没有约定履行地,给付货币的,由接收货币一方住所地为合同履行地。

背下来:

1. 仲裁机构最低设在地级市、区、县没有仲裁机构。
2. 仲裁协议签订后,当事人合并、分立的,仲裁协议对其权利义务的继受人有效,当事人另有约定的除外。

308. 东江公司因西水公司怠于行使其对南山公司的到期债权,遂对南山公司提起代位权诉讼,开庭前,南山公司提出异议,主张其与西水公司之间的合同中存在仲裁协议,故本案不属于法院主管。法院应当如何处理?(2021金题-2-4-36,单)

- A. 裁定诉讼中止,征求西水公司意见
- B. 裁定驳回南山公司异议,继续审理
- C. 裁定驳回东江公司起诉
- D. 裁定将案件移送当事人约定的仲裁机构仲裁

【分析与思路】特别强调一个问题,仲裁协议具有相对性,故同学们在判断时只需要找到纠纷双方当事人,判断他们之间是否存在有效仲裁协议,如果存在,即应当通过仲裁方式解决纠纷,不能起诉;如果不存在,则可以起诉。据此分析本题,债权人东江公司对相对人南山公司提起代位权诉讼,东江公司与南山公司之间存在仲裁协议吗?——不存在,因为本案的仲裁协议是南山公司与西水公司的合同中约定的,对东江公司并没有约束力,不能阻止东江公司对南山公司提起代位权诉讼,故法院应当驳回南山公司异议,继续审理本案。

当然,以上是基于原理的分析,同学们也可以直接根据《民法典合同编通则司法解释》第36条的规定直接得出上述结论,根据司法解释规定,债权人提起代位权诉讼后,债务人或者相对人以双方之间的债权债务关系订有仲裁协议为由对法

院主管提出异议的，人民法院不予支持。但是，债务人或者相对人在首次开庭前就债务人与相对人之间的债权债务关系申请仲裁的，人民法院可以依法中止代位权诉讼。

综上所述，本题答案为 B。

背下来：

仲裁协议具有相对性，只对仲裁协议的双方当事人有约束力。唯独存在如下三种例外：

1. 当事人订立仲裁协议后合并、分立的，仲裁协议对其权利义务的继受人有效，当事人订立仲裁协议时另有约定的除外；

2. 当事人订立仲裁协议后死亡的，仲裁协议对承继其仲裁事项中的权利义务的继承人有效但当事人订立仲裁协议时另有约定的除外；

3. 债权债务全部或者部分转让的，仲裁协议对受让人有效，但当事人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外。

故判断纠纷解决方式，只需要看纠纷双方当事人之间是否存在仲裁协议。

■ 309. 丁某向甲县人民法院起诉谢某请求归还借款 10 万元（A 诉讼）。诉讼中，丁某发现谢某已无财产，但对孔某（住所地在甲县）享有 10 万元债权，该债权已经到期，且谢某一直未向孔某主张权利。丁某遂以孔某为被告向甲县人民法院提起代位权诉讼（B 诉讼）。法院受理后，孔某提出异议，主张其与谢某之间的合同中订有仲裁条款，应将案件移送仲裁机构。关于甲县法院的处理，下列哪一选项是正确的？（2025 金题-2-4-31，单）

- A. 裁定中止对 B 诉讼的审理
- B. 将 A 诉讼和 B 诉讼合并审理
- C. 将 B 诉讼移送给仲裁机构
- D. 裁定中止对 A 诉讼的审理

【分析与思路】 本题考查代位权诉讼的主管、管辖以及代位权诉讼与债权债务诉讼的关系问题。

第一个问题，代位权诉讼的主管和管辖。代位权诉讼由被告（即相对人孔某）住所地法院甲县人民法院管辖。同时，基于仲裁协议效力的相对性，债务人或者相对人以双方之间的债权债务关系订有仲裁协议为由对法院主管提出异议的，法院不予支持。故孔某和谢某之间的仲裁协议不影响债权人丁某向甲县人民法院对相对人孔某提起代位权诉

讼，孔某的异议不成立，C 选项错误。

第二个问题，丁某对债务人谢某提起的债权债务诉讼（A 诉讼）与丁某对相对人孔某提起的代位权诉讼（B 诉讼）的关系。《民法典合同编通则解释》第 38 条规定，债权人向法院起诉债务人后，又向同一法院对债务人的相对人提起代位权诉讼，属于该法院管辖的，可以合并审理。不属于该法院管辖的，应当告知其向有管辖权的法院另行起诉；在起诉债务人的诉讼终结前，代位权诉讼应当中止。对该规定同学们可以从以下两个层次理解：首先，债权债务诉讼和代位权诉讼分别确定管辖法院；其次，为了防止冲突判决，要正确处理两个诉讼关系：①如果两个诉讼属于同一法院管辖的，可以合并审理；②如果两个诉讼属于不同法院管辖的，由于代位权请求成立需要以债权人和债务人之间的债权债务成立为前提，故代位权诉讼的审理需要以债权债务诉讼的审理结果为依据，故在债权人和债务人的债权债务诉讼审理终结前，应中止对代位权诉讼的审理。具体到本案而言，丁某对谢某提起的债权债务诉讼（A 诉讼）由甲县人民法院管辖，丁某对孔某提起的代位权诉讼（B 诉讼）也由甲县人民法院管辖，二者均由甲县人民法院管辖，甲县人民法院可以将 A 诉讼和 B 诉讼合并审理，B 选项正确，A、D 选项错误。

综上所述，本题答案为 B。

背下来：债权人起诉债务人后又对相对人提起代位权诉讼：1. 管辖法院分别确定。2. 防止冲突判决：（1）属于同一法院管辖的，合并审理；（2）属于不同法院管辖的，中止代位权诉讼，等待债权债务诉讼的审理结果。

■ 310. 甲公司与乙公司订立合同，约定乙公司向甲公司提供一批数据，合同中约定发生纠纷由 A 仲裁委仲裁。后来甲公司发现乙公司提供的数据是伪造的，故向乙公司追究责任，乙公司承认该数据是伪造，但主张该伪造的证据是由丙公司提供。甲公司欲追究丙公司的连带责任。下列表述正确的是？（2025 金题-2-4-32，多）

- A. 甲公司与乙、丙公司之间的法律关系不可分，甲公司应当一并对乙、丙公司向 A 仲裁委申请仲裁
- B. 甲公司与乙、丙公司之间的法律关系不可分，甲公司应当一并对乙、丙公司向法院起诉
- C. 甲、乙公司之间存在仲裁协议，故甲公司